

1500616-92.2021.8.26.0638

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: VANDICKSON SOARES EMIDIO

Comarca: Tupi Paulista

Foro: Foro de Tupi Paulista

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 18/11/2022

... condenando os réus pelo delito de tráfico de drogas e absolvendo-os pelo crime de associação para o tráfico.

Em memoriais, a defesa pugnou pela improcedência da ação penal em razão da ausência de provas para condenação pelos crimes imputados na denúncia. Subsidiariamente, pleiteou pela desclassificação do crime de tráfico para porte de drogas para uso pessoal em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tupi Paulista

Foro de Tupi Paulista

1ª Vara

Rua Tiradentes, 877, Tupi Paulista-SP - cep 17930-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500616-92.2021.8.26.0638 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500616-92.2021.8.26.0638

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2205400/2021 - DEL.POL.TUPI PAULISTA, 13822307 - DEL.POL.TUPI PAULISTA, 612/21/410

- DEL.POL.TUPI PAULISTA, 2205400 - DEL.POL.TUPI PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DOUGLAS MAGNO DE OLIVEIRA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VANDICKSON SOARES EMIDIO

Vistos.

O Ministério Público, por intermédio de seu Representante Legal em exercício neste juízo e no uso de suas atribuições legais, com base no incluso inquérito policial, ofereceu denúncia em face de DOUGLAS MAGNO DE OLIVEIRA e AMANDA FERREIRA LIMA, devidamente qualificados nos autos, dando-os como incursos nas penas dos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006, pela prática dos fatos delituosos narrados na peça vestibular, nos seguintes termos:

Consta da denúncia que, no dia 24 de julho de 2021, por volta das 11:35h, nas dependências da Penitenciária de Tupi Paulista, localizada na rodovia SP-294, km 667, zona rural, nesta cidade e Comarca, Douglas Magno de Oliveira adquiriu, para fins de tráfico, 77,28g (setenta e sete gramas e vinte e oito decigramas) da substância entorpecente Cannabis Sativa L, sem autorização e em desacordo com

determinação legal ou regulamentar. Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo o local a acusada Amanda Ferreira Lima transportou e trouxe consigo, para fins de tráfico e entrega ao corréu Douglas, a substância entorpecente supramencionada, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta, por fim, que ambos se associaram com o fim específico de cometerem o crime de tráfico de drogas.

Segundo o órgão ministerial, na data dos fatos, Douglas, que está preso na penitenciária local, recebeu a visita de sua companheira Amanda. Antes do término do horário estabelecido para visitação, Amanda solicitou acesso ao banheiro de uso múltiplo, sendo autorizada. Valendo-se da ausência de vigilância no local, deixou no chão um material contendo uma substância esverdeada, envolto em papel higiênico. Com o encerramento das visitas, Douglas recebeu ordem do agente de segurança para retornar à cela; no entanto, ciente da encomenda ilícita deixada por Amanda, ignorou as determinações para não ingressar no banheiro de uso múltiplo e foi até o local para captá-la.

Diante da desobediência, os agentes penitenciários seguiram Douglas, quando o surpreenderam, já no interior do banheiro do pátio, tentando apanhar do chão o invólucro deixado por Amanda.

Com o acompanhamento de Douglas, os agentes revistaram o local e encontraram o entorpecente enrolado em papel higiênico. Ao ser indagado, o réu assumiu a propriedade da droga e delatou a participação de Amanda, a qual foi a única visitante a ter acesso ao banheiro do pavilhão. Contudo, ao ser novamente ouvido, retratou-se da participação de sua companheira.

Laudo pericial de exame químico-toxicológico juntado às fls. 39/41.

O réu Douglas foi regularmente notificado (fls. 115) e ofereceu defesa prévia (fls. 151/152). A ré Amanda, por seu turno, constituiu advogado e compareceu espontaneamente nos autos, apresentando defesa prévia (fls. 177/178), tornando despicienda sua notificação.

A denúncia foi recebida em 19 de julho de 2022 (fls. 199/201) e os réus foram citados (fls. 221 e 230).

Passou-se, então, à fase instrutória, momento em que foram ouvidas as testemunhas, sendo os réus interrogados ao final (fls. 346/361).

Em alegações finais, o Ministério Público pleiteou a parcial procedência da ação, condenando os réus pelo delito de tráfico de drogas e absolvendo-os pelo crime de associação para o tráfico.

Em memoriais, a defesa pugnou pela improcedência da ação penal em razão da ausência de provas para condenação pelos crimes imputados na denúncia. Subsidiariamente, pleiteou pela desclassificação do crime de tráfico para porte de drogas para uso pessoal em relação ao acusado Douglas, e pelo reconhecimento da causa de diminuição da pena do art. 33, § 4º, da lei nº 11.343/2006, em relação à acusada Amanda.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva é parcialmente procedente.

Trata-se de ação penal pública incondicionada, objetivando apurar a responsabilidade de DOUGLAS MAGNO DE OLIVEIRA e AMANDA FERREIRA LIMA pela prática dos fatos delituosos dispostos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006.

A materialidade do delito de tráfico de entorpecentes está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 07/08), auto de exibição e apreensão com as respectivas imagens (fl. 09/11), comunicado de evento interno da unidade prisional (fl. 16) e laudo toxicológico definitivo (fls. 39/41) - o qual atestou que a substância encontrada é de uso proscrito no Brasil -, todos elementos submetidos ao crivo do contraditório e ratificados pela prova produzida em Juízo.

A autoria, por seu turno, é inconteste e atribuída aos acusados.

Osvaldo Sanches Clemente, testemunha compromissada, disse que na data dos fatos os agentes já sabiam que iria acontecer algo naquele pavilhão. Em determinado momento, a visita foi até o banheiro, sendo que o réu manteve certa distância. Como já sabiam que algo ocorreria, ordenaram que o réu não fosse até banheiro, mas ele desobedeceu, inclusive, indo ao banheiro errado. Com o término da visitação,

trancaram os demais detentos e foram até o local, acompanhados pelo réu, quando constataram que havia um invólucro, o qual foi encaminhado à polícia civil para análise. Inquirido pela acusação, respondeu: que o acusado confirmou que era o destinatário da droga; que houve a instauração de sindicância para apuração de falta grave; que soube que o réu confessou a participação de Amanda naquela sindicância. Indagado pela defesa, respondeu: que não participou da revista pessoal realizada em Amanda para adentrar à Unidade, pois estava no pavilhão VIII e esse procedimento é realizado na portaria; que, se houve a localização de algum material nas partes de Amanda, essa informação pode ser dada pelo setor da portaria, pois apenas sabia que iria acontecer algo diferente, mas não o conteúdo dessa informação; que o banheiro é de uso coletivo durante o banho de sol, mas naquela data era dia de visita; que apenas Amanda se dirigiu ao banheiro; que não avistou ninguém mais utilizando o banheiro; que, em razão da pandemia, o funcionário fica observando o sentenciado e a visita; reafirmou que apenas Amanda utilizou o banheiro; que a visita começa por volta das 8:30h e termina às 15:00h; que somente Amanda utilizou o banheiro (mais uma vez); que não se recorda a quantidade de visitantes naquela data, mas eram pouquíssimas pessoas, no máximo quatro. Osmar do Vale Holanda, testemunha compromissada, disse que estava trabalhando no pavilhão VIII quando, por volta das 9:00h, Amanda chegou para realizar a visita e adentrou no referido pavilhão, sentando-se defronte ao banheiro, ao passo que Douglas posicionou-se de costas em relação àquele local. Os agentes já sabiam que Amanda iria trazer droga, pois outra visita tinha delatado, mas no aparelho detector o funcionário viu como “bolo fecal”, não identificando como droga. O depoente e o agente Osvaldo permaneceram o tempo todo vigiando o casal, sendo que ambos não se levantaram em nenhum momento. Às 10:55h, Amanda pediu para ir ao banheiro, sendo autorizada pelo depoente. Ao retornar, os agentes advertiram do término do horário de visita, realizando o procedimento para sua saída; nesse momento, Douglas permaneceu sentado. O Diretor e o chefe do turno foram até o local e, após Amanda sair, Douglas correu em direção ao banheiro, sendo advertido pelo depoente para voltar para a cela 2. No entanto, Douglas desrespeitou a ordem e foi ao banheiro, momento em que pegou um rolo de papel higiênico. O chefe de turno, então, ordenou novamente para que Douglas retornasse à cela, foi quando ele soltou o rolo de papel higiênico e acatou a ordem. Os agentes algemaram-no para que ele acompanhasse a revista no banheiro, quando, em outro banheiro, localizaram o invólucro com as drogas enrolado em papel higiênico, pois Douglas tinha errado o local. Relatou que a droga estava no segundo banheiro, utilizado por Amanda, mas Douglas não viu, pois estava de costas, razão pela qual pensou que era o primeiro. Célio, Osvaldo e o depoente localizaram o produto esverdeado. Inquirido pela acusação, respondeu: que Douglas assumiu a propriedade da droga; que Amanda deixou a droga no local; que ninguém tinha entrado no banheiro, seja antes ou depois dos fatos, exceto Amanda; que primeiramente tirou a visita do pavilhão, para não correr risco de ser ela refém do preso. Indagado pela defesa, respondeu: que não participou da revista no scanner; que quando aparece uma mancha escura no scanner é diagnosticado como “bolo fecal”; que não presenciou a revista de Amanda no scanner, ficou sabendo apenas depois sobre o procedimento; que são quatro banheiros no pavilhão, sendo dois para uso das visitas e os outros dois para uso dos sentenciados; que a visita não é submetida à revista ao ir embora, exceto eventuais utensílios que possuir; que conhecia Amanda; que até então ela não apresentava conduta irregular, senão seria suspensa; que é comum a permissão de entrada das visitas que apresentam algum apontamento no scanner, sendo chamado médico para verificação; que na data não houve médico no local. Célio Aparecido da Silva, testemunha compromissada, disse que os fatos ocorreram em um dia de visita, quando os presos recebiam as visitas no pátio de sol em razão da pandemia de covid-19. Os agentes já tinham informações de que a visita de Douglas tentaria ingressar na unidade prisional com droga, razão pela qual acompanharam o transcorrer da visita. Minutos antes de encerrar o período de visita, Amanda foi ao banheiro, sendo a única visitante a entrar naquele local. Após, Amanda se despediu de Douglas e deixou o local, foi quando o depoente orientou Osmar para que os presos fossem recolhidos às respectivas celas, pois

perceberam que Amanda tinha ido ao banheiro para dispensar a droga ali, uma vez que, por não ser permitido contato físico, essa era a única forma encontrada por ela. Douglas, então, desrespeitou a ordem de ir para a cela e foi direto ao banheiro, sendo necessária a intervenção dos agentes. Indagado pela defesa, respondeu: que eram poucos visitantes no pavilhão, não mais do que dez; que somente Amanda utilizou o banheiro naquela data; que a visita começou cedo e foi até por volta de 11:00h; que ninguém mais utilizou o banheiro; que inicialmente Douglas se mostrou reticente, pois desobedeceu a ordem direta do funcionário e deu causa à atuação dos agentes, tentando manter seu movimento inicial, mas posteriormente viu que com a presença dos agentes não conseguiria e, dessa forma, parou, acompanhando a revista; que Douglas pegou um papel higiênico que não tinha nada, e não sabe se isso ocorreu por erro de comunicação com Amanda; que localizou o invólucro com papel higiênico amassado em um buraco que tinha no banheiro; que participou da revista no local; que a visita passou por scanner; que se lembra de Amanda, mas a visita no scanner é realizada por outro funcionário; que na revista do scanner não se recorda de ter sido encontrado algo com Amanda.

Aderson Moisés Vieira, testemunha compromissada, disse que aportou na delegacia de polícia um boletim de ocorrência da penitenciária local relatando que uma visita, de nome Amanda Ferreira Lima, teria visitado Douglas Magno de Oliveira, sendo suspeita de ter adentrado no banheiro de uso múltiplo, deixado a droga, e o preso, posteriormente, foi ao local e se apropriou do entorpecente. Relatou que colheu o depoimento dos agentes penitenciários e todos falaram que apenas Amanda Ferreira Lima utilizou o banheiro naquela data. No entanto, em sua oitiva, Amanda disse que foi submetida por cinco vezes ao scanner e nada teria sido encontrado.

Posteriormente, diante de sua conduta estranha, o preso teria sido surpreendido na posse da "maconha". Segundo os agentes penitenciários, Douglas teria admitido que a droga teria sido deixada por sua amásia. Em sua oitiva, Douglas negou a propriedade da droga e a participação de Amanda no caso. Afirmou que, apesar das evidências de que Amanda teria deixado a droga no banheiro, teria que ser admitida a falha no procedimento do scanner, pois sua versão era contundente. Na dúvida, então, o depoente não promoveu o indiciamento de Amanda e deixou a análise a critério do representante do Ministério Público.

Interrogada, a ré Amanda Ferreira Lima disse que há algum tempo era revistada de forma distinta em comparação com outras mulheres, sendo que na data dos fatos foi submetida por cinco vezes ao scanner. Não bastasse, foi levada a um quarto onde foi totalmente despida, inclusive suas roupas íntimas, sendo indagada por quatro funcionários se a depoente era ou não operada, se tinha um pênis ou uma vagina, deixando-a desconfortável. Os agentes fizeram a depoente virar de costas, abaixar, levantar e, ainda, submeteram-na novamente ao scanner. Afirmou que não portava nada quando entrou na unidade, e que a segurança deveria ter localizado algo antes de sua entrada, não depois. Inquirida pela acusação, respondeu: que não se recorda de ter utilizado o banheiro; que os fatos não ocorreram como relatado pelos agentes; que resolveu ir ao banheiro faltando menos de um minuto para o término da visitação, pois queria apenas se arrumar para sair; que os detentos estavam algemados na "gaiola", o que a deixou assustada, pois não era algo normal; que Célio entregou sua carteirinha, ocasião que perguntou se algo errado estava acontecendo, sendo respondida que não; que foi ao banheiro faltando pouco tempo para o término da visitação, e que o local não era muito utilizado em razão da pandemia, razão pela qual escolheu o momento mais adequado para ir se arrumar, pois é uma mulher trans; que passou duas vezes pelo scanner assim que chegou, depois foi ao quarto, as agentes despiram sua roupa, pediram para ela virar de costas, virou de frente, vestiu a roupa, e passou mais três vezes no scanner antes de adentrar ao pavilhão; que na quinta vez que passou pelo scanner o funcionário disse que estava tudo certo e que poderia entrar. Indagada pela defesa, respondeu: que o banheiro é de uso coletivo, dentro do pavilhão; que não sabe informar se outra pessoa utilizou o banheiro.

Interrogado, o réu Douglas Magno de Oliveira disse que está sendo acusado por algo que não fez, e que não pode responder por algo que não foi localizado em sua posse. Afirmou que os agentes se contradizem, pois um disse que havia quatro visitas,

outro afirmou ter dez, sendo que tinha bastante visita dentro do pavilhão. Relatou que o banheiro é de uso múltiplo, não sendo utilizado apenas por sua visita, e que na cadeia há vários entorpecentes escondidos, razão pela qual não é possível atribuir a propriedade da droga ao depoente. Indagado pelo juízo, respondeu que está preso por furto e tráfico, e que Célio sempre vasculha o pavilhão após o término das visitas, não sendo verdade que foi algemado na "gaiola" para acompanhar a revista, além de não ter ciência do local onde encontraram a droga, pois todos estavam nas celas. Relatou que na cadeia tem "contravenção", e que a droga não foi encontrada em sua posse, tampouco na cela que habita ou em seus pertences. Afirmou que Célio é uma pessoa muito rígida com os presos, e na data dos fatos se sentiu acuado, negando a propriedade da droga aos agentes. Narrou que é comum que algumas visitas "dão a cabeça" de uma para viabilizar sua própria entrada com ilícitos na unidade, sendo falha da vigilância, pois sua companheira foi revistada na entrada e na saída. Disse que desde o começo sustenta que a droga não é de sua propriedade, mas não foi acompanhado por nenhum defensor durante o processo administrativo, embora tenha-lhe sido prometido a nomeação de um advogado. Por fim, negou o crime imputado nestes autos. Inquirido pela acusação, respondeu: que aguardou por mais de um ano para depor em juízo, sendo transferido da unidade prisional em razão dos fatos aqui apurados; que foi coagido pelos agentes a assumir a propriedade da droga; que sempre negou ser o autor do crime, mas era ameaçado por Célio para confessar. Indagado pela defesa, respondeu: que não pediu para Amanda levar droga alguma; que em nenhum momento Amanda saiu de perto de sua companhia, indo ao banheiro somente ao final.

Pois bem.

Por tudo quanto colhido, tem-se por absolutamente incontestado a configuração dos elementos objetivos, subjetivos e normativos do tipo em comento, sendo que as versões exculpatórias apresentadas pelos acusados são contraditórias e dissonantes da realidade comprovada nos autos.

Por seu turno, as versões das testemunhas sobre os fatos são uníssonas e vão ao encontro dos elementos informativos que dão suporte à acusação. Não há por que desconfiar da palavra dos agentes de segurança penitenciária que, na qualidade de agentes públicos, possuem fé pública, gozando a presunção juris tantum de veracidade, qualidade essa que não foi afastada pela louvável defesa; longe disso, a autenticidade do teor dos depoimentos possui lastro na apreensão da droga localizada no local frequentado exclusivamente pela corré Amanda, fato esse que nem sequer foi impugnado.

Registre-se não existir qualquer indício de que os agentes tenham criado uma situação para acusar falsamente os réus. A jurisprudência dominante tem se inclinado para admitir que os testemunhos de agentes públicos, quanto aos atos de diligência no exercício de suas funções, devem merecer credibilidade desde que não evidenciada a má-fé ou abuso de poder, o que não se verifica na hipótese dos autos, tanto assim que nada se comprovou a respeito. Nesse sentido, destaco ementa que representa o entendimento desta Corte:

PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO LEGÍTIMA. IDONEIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM APRISÃO. 1) Absolvição por falta de provas.

Impossibilidade. Traficância comprovada pelo acervo probatório. Ademais, natureza, variedade e quantidade de drogas apreendidas que não deixam dúvidas sobre a destinação mercantil. Idoneidade dos depoimentos dos policiais. Entendimento consolidado por este E. Tribunal e pelo C. STF. 2) Pena Constatado pequeno equívoco na aplicação da pena de multa ao réu Diogo, vez que, devido a redução de 2/3 (dois terços) resultaria em 166 dias-multa e não 167 unidades conforme constou na r. sentença. (grifei)

(TJ-SP, Apl: 0007456-68.2012.8.26.0070, Relator: Alcides Malossi Junior, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de julgamento: 22/10/2015)

Ressalto que os depoimentos das testemunhas mostram-se harmônicos entre si e condizentes com o conjunto probatório dos autos - não havendo razões para se lançar dúvidas sobre sua credibilidade -, sobretudo ao que diz respeito às circunstâncias do crime, porquanto todas foram categóricas ao relatarem que Amanda foi a única visita a ter acesso ao local em que a droga fora apreendida, bem como que Douglas

desrespeitou a ordem dos agentes para tentar apanhá-la.

Aliás, também destaco que não há qualquer demonstração de que os agentes públicos teriam proveito com alguma mentira, pelo contrário, eles se dispuseram a cumprir seu mister com excelência, mesmo sob o risco de sofrerem falsas acusações pelas versões exculpatórias, como ocorre no caso.

Verifico, ainda, que a conduta dos agentes em não submeter a ré Amanda à revista invasiva por médico mostrou-se a mais adequada, uma vez que não havia certeza quanto ao conteúdo do material apontado no scanner. A par disso, não há qualquer falha na segurança, uma vez que os agentes se mantiveram vigilantes acerca da suspeita durante todo o período de visita, inclusive, logrando êxito em apreenderem a droga logo após ter sido dispensada pela ré.

Em que pese os esforços para a elisão da culpa, a narrativa apresentada pelos réus é eivada de contradições que infirma sua credibilidade. Amanda alega peremptoriamente que estranhou o fato de ver presos algemados na “gaiola”, algo que é incomum no cotidiano da penitenciária; Douglas, por sua vez, contradiz sua companheira ao negar que tenha ocorrido essa situação.

Outro ponto que merece relevo é quando Amanda alega, no início de seu depoimento, não se recordar de ter ido ao banheiro, mas, logo em seguida, fornece detalhes da dinâmica dos fatos sob sua perspectiva, revelando que teria ido ao sanitário minutos antes do término da visita, além de ter escolhido esse momento por ser o local pouco frequentado.

Diante disso, não remanesce qualquer dúvida de que as versões dos acusados não correspondem à realidade, mas trata-se de ardil unicamente destinado a eximi-los da imputação descrita na denúncia.

Por fim, o fato de as drogas não terem sido encontradas na posse direta do corréu Douglas não afasta a prova da autoria e materialidade delitiva, já que a dinâmica dos fatos demonstra de forma iniludível o conluio criminoso entre os corréus para introduzir drogas no interior da Unidade Prisional, o que atrai a incidência da norma extensiva prevista no artigo 29 do Código Penal.

Em se tratando de estabelecimento penitenciário, é absolutamente surreal admitir que a droga seria destinada ao consumo pessoal do réu, sobretudo diante do sistema de vigilância que, por corolário, torna escasso os entorpecentes no local. Desse modo, quando ambos se colocam em elevado risco para uma empreitada criminosa com chances remotas de êxito, presume-se por raciocínio lógico-dedutivo que o destino da droga era o consumo de terceiros.

Esclareço que não há qualquer óbice em se adotar a presunção hominis no caso em tela, já que a circunstância conhecida e provada, diante das peculiaridades que envolve o caso, permite ao juiz concluir por indução a real destinação dos entorpecentes. Sobre o tema, destaco relevante posicionamento do Supremo Tribunal Federal:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRESUNÇÃO HOMINIS. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS. APTIDÃO PARA LASTREAR DECRETO CONDENATÓRIO. SISTEMA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REAPRECIÇÃO DE PROVAS. DESCABIMENTO NA VIA ELEITA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA APTA A AFASTAR A MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06, ANTE A DEDICAÇÃO DO AGENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ORDEM DENEGADA. 1. O princípio processual penal do favor rei não ilide a possibilidade de utilização de presunções hominis ou facti, pelo juiz, para decidir sobre a procedência do ius puniendi, máxime porque o Código de Processo Penal prevê expressamente a prova indiciária, definindo-a no art. 239 como “a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias”. Doutrina (LEONE, Giovanni. Trattato di Diritto Processuale Penale. v. II. Napoli: Casa Editrice Dott. Eugenio Jovene, 1961. p. 161-162). Precedente (HC 96062, Relator (a): Min. MARÇO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 06/10/2009, DJe-213 DIVULG 12-11-2009 PUBLIC 13-11-2009 EMENT VOL-02382-02 PP-00336). 2. O julgador pode, através de um fato devidamente provado que não constitui elemento do tipo penal, mediante raciocínio engendrado com supedâneo nas suas experiências empíricas, concluir pela ocorrência de circunstância relevante para a qualificação penal da conduta. 3. A criminalidade dedicada ao tráfico de drogas organiza-se em sistema altamente

complexo, motivo pelo qual a exigência de prova direta da dedicação a esse tipo de atividade, além de violar o sistema do livre convencimento motivado previsto no art. 155 do CPP e no art. 93, IX, da Carta Magna, praticamente impossibilita a efetividade da repressão a essa espécie delitativa. 4. A reapreciação do acervo probatório é vedada na via estreita do habeas corpus, conforme a remansosa jurisprudência desta Corte Suprema. Precedentes (HC 106393, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 15/02/2011; RHC 98731, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 02/12/2010; HC 72979, Relator (a): Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em 23/02/1996; HC 93369, Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 15/09/2009). 5. In casu: (i) consta dos autos que o paciente, em concurso com um adolescente, transportava e tinha em depósito, para consumo de terceiros, 6,280 Kg (seis quilos e duzentos e oitenta gramas) de maconha, e 787,9 gramas de cocaína em pedra, acondicionadas em invólucros, disso resultando sua condenação a 5 (cinco) anos de reclusão e a 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado, por estar incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006; (ii) para fundamentar a inaplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, o Juízo de origem ponderou negativamente as circunstâncias do crime, destacando a forma como a droga estava acondicionada e o concurso de pessoas, com envolvimento de adolescente, de forma a facilitar a comercialização, tudo conduzindo à conclusão de que não se trata de uma ação individual e ocasional, mas sim que o paciente se dedicava a atividades criminosas; (iii) apesar da robusta fundamentação, sustenta o impetrante que não houve adequada motivação do arredamento da aludida minorante, pois entende que teria sido considerada apenas a quantidade da droga. 6. O juízo de origem procedeu a atividade intelectual irrepreensível, porquanto a apreensão de grande quantidade de droga é fato que permite concluir, mediante raciocínio dedutivo, pela dedicação do agente a atividades delitivas, sendo certo que, além disso, outras circunstâncias motivaram o afastamento da minorante. 7. Ordem denegada. (grifei)

(STF - HC: 101519 SP, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 20/03/2012, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-081 DIVULG 25-04-2012 PUBLIC 26-04-2012)

Não obstante, entendo que não há elementos suficientes para condenação de ambos os réus em relação ao crime de associação para o tráfico de drogas.

Conforme já pontuado, é o caso de aplicação, apenas, da norma extensiva relativa ao concurso de pessoas, prevista no artigo 29 do Código Penal. Isso porque o crime de associação exige um vínculo estável e permanente com a finalidade específica de praticar o crime de tráfico, de modo que seria necessário elementos probatórios nesse sentido para subsidiar um decreto condenatório.

O vínculo estável e permanente pressupõe uma estrutura organizada, com divisão de tarefas e cuja finalidade é a prática reiterada do crime de tráfico, ainda que não se tenha efetivamente alcançado o resultado desejado. O concurso de pessoas, no entanto, exige apenas a pluralidade de condutas, com relevância causal e liame subjetivo, dispensando prova de qualquer outra circunstância.

Malgrado os réus sejam companheiros, não há indícios de que ambos tenham engendrado um vínculo associativo para praticarem o crime em questão, de modo que a absolvição é medida de rigor.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DESCRITO NO ART. 35 DA LEI DE DROGAS.

ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NÃO DEMONSTRADAS. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. APLICAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte entende ser necessária a demonstração da estabilidade e permanência da associação para a condenação pelo crime do art. 35 da Lei n. 11.343/2006. 2. Tendo o Tribunal de origem deixado de indicar de que modo estaria efetivamente caracterizado o vínculo de estabilidade e permanência do acusado com terceiros, indispensável à configuração do crime de associação para o tráfico, limitando-se a aduzir, em síntese, que a localidade em questão é área de tráfico de drogas, de alto risco, dominada pelo Comando Vermelho. 3. Ausente os elementos da estabilidade e da permanência do delito de associação, deve ser afastada a

condenação pela prática do crime do art. 35 da Lei n. 11.343/2006, aplicando-se o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, com o redimensionamento da pena e substituição da pena privativa por restritivas. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 592909 RJ 2020/0156378-4, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 27/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 12/11/2020 DJe 03/11/2020)

Diante desse cenário, verifico que a imputação é consentânea apenas em relação ao crime de tráfico de drogas, estando presentes os elementos objetivos, subjetivos e normativos do tipo, mormente porque "indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado"

(MIRABETE, Júlio F., in Processo Penal - 17ª ed. São Paulo: Atlas, 2005, p. 344). Sob essa ótica, passo a individualizar a pena, de modo fundamentado e seguindo os parâmetros do artigo 68, caput, do Código Penal.

DOSIMETRIA DA PENA.

Em relação ao réu DOUGLAS MAGNO DE OLIVEIRA:

Na primeira fase, analisando-se as circunstâncias judiciais descritas nos artigos 42 da Lei nº 11.343/06 e 59, caput, do Código Penal, as circunstâncias não são favoráveis o réu, o qual possui maus antecedentes por três condenações (fls. 86, processo nº 0000090-98.2014.8.26.0072 - art. 129, § 9º, CP; fls. 86, processo nº 0002298-55.2014.8.26.0072 - art. 155, CP; fls. 89, processo nº 0006181-64.2012.8.26.0400 - art. 19, DL 3.688/41). Aqui, abro um parêntese para esclarecer que, malgrado a condenação anterior por contravenção penal não caracterize reincidência, é apta a ser considerada como reveladora de maus antecedentes (STJ, HC 396.726/SP, Quinta Turma, Min. Reynaldo Soares da Fonseca); ainda, "as condenações criminais cujo cumprimento ou extinção da pena ocorreu há mais de 5 anos, a despeito de não implicarem reincidência nos termos do que dispõe o art. 64, I, do CP, são hábeis a caracterizar maus antecedentes" (STJ - REsp: 1717020 RJ 2017/0334168-3, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 19/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2018). As circunstâncias do crime também escapam à normalidade inerente à espécie, porquanto o réu descumpriu deliberadamente a determinação do agente penitenciário para adentrar à cela, dirigindo-se ao banheiro sem permissão, sendo necessária a intervenção de outros agentes, inclusive do diretor de plantão, para imobilizá-lo. Todos os demais elementos são inerentes ao tipo penal, razão pela qual fixo a pena-base em 1/3 (um terço) acima do mínimo legal, resultando em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, verifico que o réu é multirreincidente, inclusive, com condenação transitada em julgado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 61, I, do CP - fls. 87, processo nº 0003247-27.2016.8.26.0072 - art. 155, CP; fls. 88, processo nº 0002787-73.2017.8.26.0400 - art. 33, SISNAD). Destarte, impõe-se um agravamento de 1/5 (um quinto) às penas anteriormente fixadas, resultando em 8 (oito) anos de reclusão e pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa.

Na terceira fase, verifico presente a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista que a infração ocorreu nas dependências de estabelecimento prisional. Assim, aumento em 1/6 (um sexto) a pena, tornando-a definitiva em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa.

Diante dos maus antecedentes e da reincidência específica, considero inaplicável o benefício previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, uma vez que o réu não preenche o requisito subjetivo para concessão da benesse. Nesse sentido, o TJSP: Apelação. Tráfico de drogas. Recurso defensivo. Da ré Paloma - pleito absolutório por fragilidade probatória. Pleitos subsidiários: redução da pena ao final imposta. Do réu Alexandre - pleito que visa a incidência da atenuante da confissão espontânea, o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado e a redução da pena de multa imposta ao acusado diante de sua precária situação financeira. 1.

Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos dos policiais uniformes e convergentes. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de

prova em sentido contrário. Modelo probatório que não se filiou ao sistema das provas legais segundo o qual os meios de prova registrariam valores aprioristicamente determinados pelo legislador. Livre convencimento motivado. 2. Dosimetria da pena que merece reparos. 2.1 - Do réu Alexandre - réu que possui três condenações pretéritas definitivas que permitem o rateio entre antecedentes e reincidência. Precedentes do STF e STJ. Quantidade expressiva de cocaína. Aplicação da pena base acima do mínimo legal e com o acréscimo de 1/5. Convergência da agravante da reincidência com o aumento da pena em 1/6. Reincidência que impede a aplicação da figura do tráfico privilegiado e que justifica a imposição de regime prisional mais severo, afastando a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Isenção do pagamento da pena de multa. Inviável. 2.2 - Da ré Paloma - ré que possui quatro condenações pretéritas definitivas que permitem o rateio entre antecedentes e reincidência. Precedentes do STF e STJ. Quantidade expressiva de cocaína. Aplicação da pena base acima do mínimo legal e com o acréscimo de 1/5. Convergência da agravante da reincidência com o aumento da pena em 1/6. Reincidência que impede a aplicação da figura do tráfico privilegiado e que justifica a imposição de regime prisional mais severo, afastando a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 3. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Grifei.

(TJ-SP - APR: 15003963720208260539 SP 1500396-37.2020.8.26.0539, Relator: Marcos Alexandre Coelho Zilli, Data de Julgamento: 16/08/2021, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/08/2021)

Não possuindo elementos para averiguar a situação financeira do acusado, fixo o valor de cada dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, corrigidos monetariamente pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde a prática delituosa.

Em atenção ao artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal, estabeleço o regime inicial fechado para o cumprimento da pena.

Não há que se falar em substituição da pena por restritivas de direito (art. 44, CP), nem aplicação da suspensão condicional da pena (art. 77. CP), uma vez que a sanção aplicada supera o limite máximo estipulado pelo legislador.

Em relação à ré AMANDA FERREIRA LIMA:

Na primeira fase, analisando-se as circunstâncias judiciais descritas nos artigos 42 da Lei nº 11.343/06 e 59, caput, do Código Penal, as circunstâncias não são favoráveis à ré, a qual possui maus antecedentes por uma condenação (fls. 99 - processo nº 0000035-30.2009.8.26.0297 - art. 157, § 3º, CP). Ademais, a culpabilidade extrapola as circunstâncias inerentes ao tipo, porquanto restou comprovado que a ré dissimulou a substância entorpecente dentro de seu próprio corpo com a finalidade de burlar a vigilância, comprometendo o trabalho das agentes que realizaram a revista, fato que deve ser sopesado em seu desfavor. Todos os demais elementos são inerentes à espécie, razão pela qual fixo a pena-base em 1/5 (um quinto) acima do mínimo legal, resultando em 6 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas, mantidas as penas no patamar anterior.

Na terceira fase, verifico presente a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista que a infração ocorreu nas dependências de estabelecimento prisional. Assim, aumento em 1/6 (um sexto) a pena, tornando-a definitiva em 7 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Diante dos maus antecedentes, considero inaplicável o benefício previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, uma vez que a ré não preenche o requisito subjetivo para concessão da benesse. Nesse sentido, a Corte de Cidadania:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO PELA RELEVANTE QUANTIDADE DE DROGA E PELOS MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTOS VÁLIDOS. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO ESPECIAL ANTE OS MAUS ANTECEDENTES. ILEGALIDADE INEXISTENTE. REQUISITO LEGAL NÃO ATENDIDO. TESE DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA

PROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não se constata a alegada falta de fundamentação para a exasperação da pena-base, ante a elevada quantidade de droga apreendida - 9 kg de maconha, nos exatos termos do art. 42 da Lei 11.343/06 - e os maus antecedentes do apenado, não havendo falar em ilegalidade ou em "bis in idem" ante a utilização do fundamento como óbice à concessão da minorante na terceira fase da dosimetria, tendo em vista o não preenchimento de um dos requisitos legais consubstanciado nos "bons antecedentes". 2. Tampouco se constata ofensa ao princípio da proporcionalidade no que diz respeito ao aumento em 2 anos e 200 dias-multa relativo à valoração negativa de duas vetoriais, tendo em vista, sobretudo, as penas mínima e máxima abstratamente cominadas. 3. Nos termos do entendimento desta Corte, salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou patente desproporcionalidade, não é possível o reexame dos critérios de individualização da pena na via do especial, sendo que a exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, sendo admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada aos elementos concretos dos autos. 4. Agravo regimental improvido. Grifei.

(STJ - AgRg no AREsp: 1848787 TO 2021/0070591-7, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 19/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2021)

Não possuindo elementos para averiguar a situação financeira da acusada, fixo o valor de cada dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, corrigidos monetariamente pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde a prática delituosa.

Em atenção ao artigo 33, § 3º, do Código Penal, estabeleço o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, em razão dos maus antecedentes e da culpabilidade acentuada da ré, tudo a indicar que o regime intermediário não é suficiente para produzir um efeito dissuasório de sua conduta.

Não há que se falar em substituição da pena por restritivas de direito (art. 44, CP), nem aplicação da suspensão condicional da pena (art. 77. CP), uma vez que a sanção aplicada supera o limite máximo estipulado pelo legislador.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória para:

1) CONDENAR o réu DOUGLAS MAGNO DE OLIVEIRA, devidamente qualificado nos autos deste processo crime, como incurso nas penas do artigo 33, caput, c.c. art. 40, III, da lei nº 11.343/2006, na forma do artigo 29 do Código Penal, a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa, no valor mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) de salário mínimo vigente à época dos fatos, corrigido monetariamente pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde a prática delituosa;

2) CONDENAR a ré AMANDA FERREIRA LIMA, devidamente qualificada nos autos deste processo crime, como incurso nas penas do artigo 33, caput, c.c. art. 40, III, da lei nº 11.343/2006, na forma do artigo 29 do Código Penal, a 7 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, no valor mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) de salário mínimo vigente à época dos fatos, corrigido monetariamente pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde a prática delituosa.

Considerando que não existe fato superveniente que ensejaria a decretação da prisão preventiva, concedo aos réus o direito de recorrerem em liberdade.

Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, ante a inexistência de pedido, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Concedo aos acusados os benefícios da justiça gratuita, razão pela qual deixo de condená-los nas custas processuais.

Oportunamente, após o trânsito em julgado da presente ação criminal, tomem-se as seguintes providências:

Expeça-se mandado de prisão, com a respectiva guia de recolhimento, provisória ou definitiva, conforme o caso, bem como carta de guia;

Autorizo a incineração da substância entorpecente, guardando-se apenas o suficiente para eventual contraprova, que, após o trânsito em julgado, também deverá ser incinerada;

Em cumprimento ao disposto no artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral, oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação da ré, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia da presente decisão, para cumprimento do quanto estatuído no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; Oficie-se ao órgão estadual de cadastro de dados sobre antecedentes criminais, fornecendo as informações sobre a condenação da ré.

A presente sentença servirá, por cópia digitada, como os ofícios necessários, devendo ser instruída com os documentos pertinentes.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as anotações necessárias.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Tupi Paulista, 11 de novembro de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vandickson Soares Emídio

O/A Magistrado/a assina digitalmente, nos termos da lei 11.419/2006, conforme impressão à margem direita.
